

1500197-87.2022.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2039351/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 22950460 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 405/22/316 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2039351 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500197-87.2022.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-87.2022.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2039351/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 22950460 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 405/22/316 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2039351 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2039351/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON VINICIUS FERREIRA DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

WANDERSON VINICIUS FERREIRA DE SOUSA e WENDER HENRIQUE MENDES DO LAGO, já qualificados nos autos da ação penal em epígrafe, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 14:00 horas, na Rodovia SP 340, km 165, bairro Aguardente do Reino, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, agindo em conjunto com o adolescente Kauan Henrique Pinto, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 45 (quarenta e cinco) comprimidos de Ecstasy, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, Policiais Militares Rodoviários que realizavam patrulhamento de rotina tiveram a atenção despertada pelo comportamento suspeito dos ocupantes de um veículo (o motorista freou bruscamente o automóvel e todos fecharam os vidros tão logo notaram a ultrapassagem feita pela viatura) e, por isso mesmo, deliberaram abordá-los. Feitas as buscas pessoais, tais agentes públicos encontraram R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) com o corréu WANDERSON (condutor do automóvel) e R\$ 5,00 (cinco reais) com o corréu WENDER (passageiro); com o adolescente Kauan, por fim, nada foi encontrado. Questionado, porém, este último disse que haviam adquirido 45 (quarenta e cinco) comprimidos de Ecstasy de um motoqueiro, dos quais 30 (trinta) pertenceriam a ele e 15 (quinze) ao corréu WENDER; WANDERSON, por sua vez, teria sido contratado para buscar o entorpecente. Quando da inspeção do veículo, outrossim, localizaram-se nos dutos do sistema de ar-condicionado do veículo os comprimidos de Ecstasy, além de 01 (uma) porção de maconha que o corréu WANDERSON disse destinar-se ao seu próprio consumo.

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/122 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente, e com o Relatório da Autoridade Policial.

Os acusados foram então regularmente notificados e apresentaram resposta escrita, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 147, 184, 198, 200 e 204/205). Recebida a denúncia, seguiram-se as citações pessoais (fls. 211/212, 230 e 232).

Na audiência atermada a fls. 233/234, interrogaram-se os réus e ouviram-se 02 (duas) testemunhas. Quando dos debates, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia; o I. Defensor constituído pelo corréu WANDERSON, ao seu turno, postulou a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena sem seu grau mínimo, a adoção de regime semiaberto e o apelo em liberdade.

Em memoriais (escritos), o I. Defensor constituído pelo corréu WENDER bateu-se pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, pelo afastamento da causa de aumento de pena inscrita no artigo 40, III, daquele diploma legal, pela aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º, também da Lei nº 11.343/06, além da adoção do regime inicial aberto e do apelo em liberdade (fls. 238/240).

Relatados, D E C I D O.

Cuida-se de tráfico de drogas (que envolveu adolescente), delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Enquanto a materialidade descende da prova consubstanciada no auto de exibição e

apreensão e no laudo pericial encartados a fls. 32/33 e 131/133, a autoria restou suficientemente demonstrada em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas de forma segura e coesa, sem dúvidas ou contradições capazes de recomendar algum descrédito.

Como se infere do incluso auto de prisão em flagrante, Policiais Militares Rodoviários que realizavam patrulhamento de rotina tiveram a atenção despertada pelo comportamento suspeito dos ocupantes de um veículo (o motorista freou bruscamente o automóvel e todos fecharam os vidros tão logo notaram a ultrapassagem feita pela viatura) e, por isso mesmo, deliberaram abordá-los. Feitas as buscas pessoais, tais agentes públicos encontraram R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) com o corréu WANDERSON (condutor do automóvel) e R\$ 5,00 (cinco reais) com o corréu WENDER (passageiro); com o adolescente Kauan, por fim, nada foi encontrado. Questionado, porém, este último disse que haviam adquirido 45 (quarenta e cinco) comprimidos de Ecstasy de um motoqueiro, dos quais 30 (trinta) pertenceriam a ele e 15 (quinze) ao corréu WENDER; WANDERSON, por sua vez, teria sido contratado para buscar o entorpecente. Quando da inspeção do veículo, outrossim, localizaram-se nos dutos do sistema de ar-condicionado do veículo os comprimidos de Ecstasy, além de 01 (uma) porção de maconha que o corréu WANDERSON disse destinar-se ao seu próprio consumo.

Dir-se-á não ter validade a referida prova, porquanto produzida na fase inquisitorial, onde não se atenta para os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se deslembre, entretanto, da sua renovação em Juízo, advindo daí inquestionável credibilidade.

Quando ouvidos durante a instrução criminal, os Policiais Militares Rodoviários Bruno Bonato e Jonatas Delfino ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dados ao Delegado de Polícia que presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante; reafirmaram não apenas aquele comportamento suspeito (adotado pelos ocupantes do veículo) que justificou e deu razão de ser à abordagem, mas também, e principalmente, a apreensão de dinheiro, a confissão parcial dada pelo adolescente e a localização da substância entorpecente nos dutos do sistema de ar-condicionado do automóvel.

E a despeito do entendimento comumente esposado em casos deste jaez, não há como inquinar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais (raciocínio extensível aos membros das Guardas Municipais), mormente quando ausente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial (ou Guarda Municipal) não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 – SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes

do STF e desta Corte (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL - Depoimento de Policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas - Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95).

PROVA CRIMINAL - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida. O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a Juízo para perseguir pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes (Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - Relator: Djalma Lofrano - 18.08.94).

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95).

Aliás, "seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito" (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11a Câmara - Relator: Xavier de Aquino).

As negativas expendidas pelos acusados por ocasião dos interrogatórios, então, restaram isoladas e, por isso mesmo, sem aptidão para infirmar os elementos de prova deveras sólidos produzidos em seu desfavor.

O corréu WENDER até admitiu ter encomendado 05 (cinco) comprimidos de Ecstasy ao adolescente; negou saber, contudo, que aquela viagem se destinava exatamente à busca da droga, cuja existência chegou ao seu conhecimento apenas e tão somente após a apreensão feita pelos Policiais Militares Rodoviários. O corréu WANDERSON, por sua vez, disse trabalhar como motorista de aplicativo ("Uber") e ter sido contratado para buscar "ingressos", razão pela qual só soube da droga quando da abordagem policial.

Nada mais fantasioso e ilógico.

A uma, pois se a viagem se destinava à aquisição de drogas, não é crível que o adolescente se valesse de pessoas que desconhecem seu intento e, por isso mesmo, não adotariam as cautelas necessárias e suficientes a evitar a apreensão daquelas

substâncias tão valiosas quanto ilícitas.

A duas, pois a mais singela e despreocupada leitura dos relatos dados pelo Policiais Militares Rodoviários autoriza inferir, indene de dúvidas, que a abordagem se deveu única e exclusivamente ao comportamento suspeito de todos os ocupantes do veículo ao avista a viatura (enquanto o condutor freou bruscamente, os demais subiram rapidamente os vidros e se agitaram no interior do automóvel). E afastada a remota hipótese de alguém adotar tal comportamento sem nada de ilícito, é de pronta inteligência que todos sabiam da existência da droga e, por esta exata razão, mentiram acintosa e deslavadamente em juízo.

A três, pois tais agentes públicos afirmaram, categoricamente, que o adolescente ocupava o banco traseiro do automóvel. E se a droga foi escondida nos dutos do sistema de ar-condicionado existentes na parte frontal do veículo, difícil – senão impossível – crer pudesse ela lá estar sem o conhecimento daqueles que ocupavam os dois bancos dianteiros (corréus WENDER e WANDERSON).

E fixada a responsabilidade de ambos os réus pela droga apreendida, nem se faz necessária maior digressão para afastar a subsunção de sua conduta à regra do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

À quantidade de droga apreendida (nada menos que 45 comprimidos), somam-se a confissão informal dada aos Policiais Militares Rodoviários (a droga teria sido adquirida a R\$ 19,00 a unidade e seria revendida em festas “raves” a R\$ 50,00), a inexistência de referência precisa dos próprios réus a destinação diversa (qual seja, uso próprio) e, no caso do corréu WANDERSON, a existência de anterior condenação por idêntica infração penal.

Embora possível, os acusados não comprovaram a origem lícita dos valores encontrados consigo. Daí concluir-se tratar-se mesmo de proveito auferido com o tráfico de entorpecentes e, por isso mesmo, a pertinência do perdimento. Para VICENTE GRECO FILHO, outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá o acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes. Algo intuitivo, aliás, porque a ressabida inexistência de registros formais acerca da origem de numerário e bens em casos deste jaez torna absolutamente impossível carrear à acusação a prova de tal ilicitude.

Confira-se ainda, porque relevante, o ensinamento de PAULO JOSÉ DA COSTA JR., para quem a lei penal previu o confisco dos instrumenta sceleris (art. 91, I) e dos producta sceleris (n. II, b)... Instrumentos do rime são os utensílios que se prestam ao seu cometimento. Confisco é a perda de bens do particular em favor do Estado. Nem todos os instrumentos poderão ser confiscados, mas somente aqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção configurem um ilícito... Produtos do crime são as coisas obtidas diretamente com a infração (res furtiva), mediante operação subsequente (jóia fabricada com o ouro furtado), criadas pelo crime (moeda falsa), ou adquiridas com a alienação dos objetos furtados. Apreendidos os instrumentos e o produto do crime, serão destruídos (CPP, art. 124), leiloados (CPP, arts. 122 e 123), ou recolhidos a museu (CPP, art 124)... Os instrumentos apreendidos pela autoridade policial, desde que relacionados com o crime, não poderão ser restituídos a seus titulares enquanto interessarem ao processo e durante toda a sua tramitação (CPP, arts. 6º e 118). A apreensão antecede o confisco. É pressuposto deste. Destaquei.

Não é caso, todavia, de se determinar o perdimento do automóvel apreendido, pois a providência contemplada no artigo 34 da Lei nº 6.368/76, hoje inserta no artigo 62 da Lei nº 11.343/06, há de se restringir àqueles casos em que tais bens são direta e intencionalmente colocado como “instrumento” do crime. Colha-se, dentre outros, o escólio de VICENTE GRECO FILHO, para quem a excessiva amplitude do texto legal

exige uma interpretação restritiva, sob pena de chegarmos ao absurdo, p. ex., vermos a perda de um automóvel só porque nele foram encontrados “pacaus” de maconha. Para a perda, repetimos, há necessidade de um nexó etiológico entre o delito e o objeto utilizado para a sua prática. No caso em voga o inquérito policial não contém relatórios de investigações capazes de sugerir a reiterada e constante utilização daquele veículo como “instrumento” do comércio deveras espúrio de entorpecentes. Daí não ser caso de perdimento.

WANDERSON VINICIUS FERREIRA DE SOUSA e WENDER HENRIQUE MENDES DO LAGO, então, praticaram fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante as suas culpabilidades, impõem-se-lhes as respectivas sanções penais que passo a dosar.

I – Do corrêu WANDERSON:

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a inexistência de relevantes antecedentes criminais (tirante aquela condenação proferida nos autos da ação penal nº 1500455-80.2019.8.26.0144 cujo trâmite se deu perante a Vara Única da Comarca de Conchal e há de ser considerada na próxima fase da dosimetria da pena) ou outros elementos capazes de justificar alguma exasperação da sanção (embora não fosse desprezível, a quantidade de droga não assume proporções ímpares que justifiquem algum acréscimo nesta fase). Fixo a pena base, então, em 05 (cinco) anos de reclusão.

O documento encartado a fls. 141/142 indica mesmo a reincidência, circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. Daí acréscimo, à razão de 1/6, para perfazer 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes.

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que o tráfico foi cometido na companhia de adolescente, advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Faz-se, então, derradeiro acréscimo, também à razão de 1/6 (um sexto), de modo a alcançar 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há, por fim, causas gerais ou especiais diminuição de pena (à vista da reincidência, não é caso de se dar vigência ao redutor inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade, dessarte, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, previsão legal mínima para o delito modificada, na mesma proporção, pelos acréscimos proporcionados pela circunstância agravante (reincidência) e pela causa de aumento de pena (crime perpetrado na companhia de adolescente). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira deste corrêu.

II – Do corrêu WENDER:

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre anotar a inexistência de relevantes antecedentes criminais ou outros elementos capazes de justificar alguma exasperação da sanção. Fixo a pena base, então, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que o tráfico foi cometido na companhia de adolescente, advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Daí acréscimo, à razão de 1/6 (um sexto), de modo a alcançar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Com relação às causas de diminuição de pena, não há como refugir à aplicação daquela inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Faz-se redução, então, à razão de 2/3 (dois terços).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade deste primeiro acusado, dessarte, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, previsão legal mínima para o delito modificada, na mesma proporção, pelo acréscimo proporcionado pela causa de aumento de pena (artigo 40, III, da Lei de Tóxicos) e pela redução proporcionada pela causa de diminuição da pena (artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira deste corréu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO I) WANDERSON VINICIUS FERREIRA DE SOUSA, já qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e 61, I, do Código Penal e; II) WENDER HENRIQUE MENDES DO LAGO, também qualificada, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, e § 4º, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Sem prejuízo, DECRETO o perdimento em favor da União (SENAD) dos valores apreendidos com o acusado.

Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao corréu WANDERSON por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime perpetrado é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Salles Abreu - 04/10/2011).

E ainda:

PENA - Restritivas de direitos - Tráfico de entorpecentes - Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) - Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 17/08/2006).

PENA - Restritivas de direitos - Réu condenado por tráfico de entorpecentes - Substituição da reprimenda privativa de liberdade - Inadmissibilidade - Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 27/09/2006).

E aqui, como já registrado alhures, tal acusado é reincidente (específico, não se olvide).

Não tem, por isso mesmo, direito à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial do cumprimento das penas impostas há de ser o fechado, único compatível com a gravidade do crime, com a quantidade da sanção e, sobretudo, com a reincidência.

Presentes em relação ao corréu WANDERSON os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade (HC nº 867.918-3/3 - Araraquara - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Sérgio Rui - 06/10/2005 - V.U.; HC nº 517.60/0-00 - São Paulo - 13ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lopes da Silva - 09/06/2005 - V.U.). À gravidade objetiva do crime (daqueles equiparados aos hediondos e que, por isso mesmo, evidenciam periculosidade do agente, soma-se a reincidência específica. E se a despeito de inquérito, processo, condenação e prisão anteriores insiste em traficar, demonstra personalidade voltada para o crime, além da absoluta ineficácia dissuasória da sanção imposta na ação penal pretérita. Daí a estrita necessidade da custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça. Recomende-se, pois, tal acusado na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a expedição de novo mandado de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendido, os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Com relação ao corréu WENDER e, à vista da primariedade, da pena aplicada e, sobretudo, da superveniência de lei que excluiu a hediondez para o caso em testilha (artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19), não há como refugir à presença dos requisitos alistados no artigo 44 do Código Penal. Daí porque, deverá tal corréu cumprir prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social indicada pelo Juízo da Execução, além de prestar serviços à comunidade pelo mesmo período da sanção ambulatorial, na forma e condições estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Sobrevindo o descumprimento da sanção, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a tal acusado será o aberto (artigo 33, § 2º, do Código Penal).

Ausentes (em relação a ele) os fundamentos da prisão preventiva, faculto o apelo em liberdade.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03).

P.R.I.C.

Mogi Mirim, 03 de novembro de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA